

1500446-38.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ALMEIDA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

GUILHERME ALMEIDA DE MORAES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500446-38.2022.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 07/05/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500446-38.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ALMEIDA DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS.

GUILHERME ALMEIDA DE MORAES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/02, a saber:

"Segundo consta dos presentes autos de comunicação de prisão em flagrante que, no

dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 14h e 30 minutos, na Rua Arnaldo Marques Carreira, 340, bairro Guapiranga, município de Itanhaém, GUILHERME ALMEIDA DE MORAES, qualificado às Fls. 06, portava, 2 microtubos com COCAINA, e, guardava na base de um poste de luz de iluminação pública, para fins de consumo de terceiros, outros 6 microtubos semelhantes aos primeiros contendo as mesmas substâncias, drogas que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No local, também foi encontrado junto com as drogas, uma quantia em espécie de R\$ 10,00 (dez reais), fruto de comércio ilícito"

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 08/11), o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), o auto de constatação preliminar de substância entorpecente apreendida (fls. 15/16), a nota de culpa (fl. 18) e o relatório lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 84/85). Ulteriormente foi anexado aos autos o laudo toxicológico (fls. 126/128).

Por ocasião da audiência de custódia (41/42), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com esteio no art. 312 do Código de Processo Penal, por entendê-la necessária à garantia da ordem pública (fls. 43/46).

Preenchidos os requisitos legais, foi recebida a denúncia, determinando-se a citação do acusado, para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 49/50). Citado, apresentou defesa prévia por intermédio de defensor constituído à fl. 71. Por não ser o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento por plataforma remota (fls. 93/95). Comprovante de depósito judicial à fl. 102.

Na solenidade, iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas Elcio e Reinaldo, arroladas em comum pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. Nos debates, a acusação protestou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado, sob a égide da anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Guilherme Almeida de Moraes nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 15/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e, principalmente, pelo laudo toxicológico de fls. 126/128, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de cocaína (2,4g). A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, ressuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado em solo policial (fls. 06/07), o inculcado permaneceu silente. Em Juízo, na essência, negou os fatos. Disse que se encontrava no local na qualidade de usuário e que não desenvolvera a atividade espúria capitulada na denúncia. Salientou ter adquirido dois microtubos de cocaína, desconhecendo a existência das demais porções, estas encontradas na base do poste de iluminação.

Todavia, quando confrontada a versão externada pelo acusado com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se

de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O policial civil Élcio, em seu depoimento prestado em solo indiciário (fl. 04) e em Juízo, asseverou que na fatídica data, na companhia de seu parceiro Reinaldo Barbosa Santos, atuava no âmbito da Operação Carnaval, diligenciando pelas imediações desta cidade em viatura descaracterizada. Salientou que ao se aproximarem do local dos fatos, observaram um indivíduo em atividade suspeita, o qual pegou um objeto escondido atrás de um poste e levou para uma outra pessoa. No momento em que se aproximaram, o suposto adquirente se afastou, razão pela qual abordaram o primeiro indivíduo, identificando-o como Guilherme Almeida de Moraes. Em suas mãos foram encontrados dois microtubos contendo pó branco conhecido como Cocaína. Ao indagarem-no, o acusado confessou informalmente a narcotraficância empreendida, bem como indicou onde estava o restante dos entorpecentes, ou seja, na base do poste, local em que foram encontrados mais seis microtubos semelhantes aos primeiros, juntamente da importância de R\$10,00 em espécie, dentro de uma sacola de mercado.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial civil Reinaldo quando de seu depoimento em solo policial (fl. 5) e sob o crivo do contraditório.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os policiais civis, durante operação de combate do narcotráfico, avistaram o acusado em ponto conhecido pela traficância retirar algo de trás de um poste e o entregar para terceiros. Diante da conduta suspeita, resolveram abordá-lo, átimo em que lograram encontrar em seu poder dinheiro em espécie, bem como o estupefaciente.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que as circunstâncias que envolveram o caso (a forma como estava acondicionado o entorpecente e apreensão de dinheiro com o réu), transparecem a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adredemente preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Não bastasse todo o cenário enredado, em poder do réu fora encontrada parte da droga.

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros. A tudo isso, some-se o fato de já ter sido o réu condenado por

idêntico delito, em recente data, conforme se infere da folha de antecedentes acostada aos autos.

Pondere-se, outrossim, que embora pequena a quantidade de estupefaciente encontrada, dúvida não resta acerca de sua finalidade mercantil, cabendo destacar que a venda fracionada do entorpecente trata-se de corriqueiro expediente utilizado por traficantes, justamente para se esquivarem de investidas policiais.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

“o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip p; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DA PERDA DOS BENS:

Pela legislação em vigor, são três os tipos de bens que podem ser apreendidos: a) produtos do crime (artigo 60): vantagem direta obtida com a prática criminosa. Ex: o dinheiro recebido com a venda da droga; b) proveito auferido (artigo 60): é a vantagem indireta, conseguida a partir do produto, v.g., um carro comprado com a venda da droga; c) veículos, embarcações, aeronaves, maquinários, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática de crimes previstos na Lei (artigo 62).

Ademais, acentua a doutrina mais judiciosa que para a decretação da perda dos bens e valores apreendidos, mostra-se necessária a demonstração do nexo etiológico a os unir com o crime apurado.

Dito isso, tenho ser o caso de se decretar o perdimento do dinheiro (R\$ 10,00, fl. 102) apreendido. Como se sabe, o tráfico conta com um mínimo de aporte para facilitar a mercancia da droga. Restando, pois, demonstrada a conduta criminosa, caberia ao réu indicar a origem do dinheiro, o que em nenhum momento se prestou a fazer.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal.

Não obstante reincidente (fl. 39), o acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva (fora dos casos de reincidência), tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer,

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a

pena-base do condenado”(STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram azealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias e as consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Presente a agravante da reincidência (vide certidão de fl. 04 do apenso - condenação pelo crime de tráfico, processo nº 0003322-44.2020.8.26.0158, 2ª Vara da Comarca de Itanhaém). A este respeito, anoto que, se uma exasperação da reprimenda é de rigor, estando presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em se tratando de um caso de reincidência específica, a resposta punitiva do Estado deve se fazer sentir com maior severidade, porquanto evidenciados o fracasso das penas anteriormente impostas, sobretudo em sua finalidade preventiva específica, e a recalcitrância do réu em amoldar sua conduta a padrões dignos de conduta. Assim, agravo a pena em 1/5, por se tratar de reincidência específica.

"(...) O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação.2. In casu, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/4, fração de aumento que não se mostra desarrazoada, tendo em vista escorreita valoração dada diante da reincidência específica do paciente. Não há falar, pois em constrangimento ilegal. (...)”(STJ-HC: 397898 RJ-2017/0097255-9. Relator: Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA. DJ: 23/05/2017, T6. DP: DJe30/05/2017).

Ausentes quaisquer atenuantes, inclusive da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inc. III, “d”, do CP, na medida em que opôs o acusado fato impeditivo à pretensão acusatória, ao argumentar tratar-se de usuário.

Ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, inclusive a prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em face da reincidência do acusado.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 935.967 AgR; Rel. Min. Edson Fachin; Primeira Turma; J.:15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, considerando o quantum de pena aplicada, bem como a condenação anterior ostentada pelo réu, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do art. 44 do Código Penal. Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos artigos 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

"remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal." E isso por se entender que "o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material."

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

Todavia, mesmo que assentadas tais premissas, as circunstâncias do caso indicam não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, a suspensão condicional de sua execução. Como já positivado, além de a pena aplicada afrontar o requisito legal, o acusado é reincidente.

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado GUILHERME ALMEIDA DE MORAES, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dado o contexto de vulnerabilidade financeira denotada.

Por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os fundamentos elencados na decisão de fls. 43/46, não reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se-o no ergástulo em que se encontra até o trânsito em julgado (artigo 387, §1º, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB – Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s). Expeça-se certidão com o trânsito em julgado.

Decreto a perda em favor de entidade beneficente cadastrada neste Juízo do dinheiro apreendido (vide fl. 102, R\$ 10,00 reais).

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84.
4. Transfira-se para entidade beneficente o dinheiro apreendido (fl. 102, R\$ 10,00 reais);
5. Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias. Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, nos termos do art. 480-A das NSCGJ, extraia a serventia certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público (ato ordinatório – cód. 505790). Havendo interposição recursal, i-se-a quando do trânsito em julgado.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA